

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、麻薬であるヘロインの粉末を覚醒剤と誤信して営利目的で輸入した。ヘロインの営利目的輸入罪と覚醒剤の営利目的輸入罪の法定刑は同一であった。この場合、甲には、覚醒剤の営利目的輸入罪が成立する。
2. 暴力団組員甲は、配下の組員乙に対し、抗争状態にある暴力団組員Aとの間でもめごとが起きた場合にはAを殺害してよいが、実際にAを殺害するかは乙の判断に任せる旨伝えて拳銃を渡し、乙も了承したところ、乙は、Aともめたことから、殺意をもってAを射殺した。甲が乙とAの間でもめごとが起きることがあり得ると認識していた場合、甲には、殺人罪の故意が認められる。
3. 甲は、殺意をもってAに向けて拳銃を発射したところ、その弾丸がAを貫通し、その背後にいて甲がその存在を認識していなかったBにも命中し、その結果、Aが死亡し、Bが重傷を負った。この場合、甲には、Aに対する殺人罪が成立するが、Bに対する殺人未遂罪は成立しない。
4. 甲は、乙にAへの暴行を教唆し、乙もその旨決意し、Aに暴行を加えて死亡させたが、甲は同教唆の時点でAが死亡する可能性を予見していなかった。この場合、甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
5. 甲は、殺意をもってAの首を絞めたところ、Aが動かなくなったので、Aが死亡したものと誤信し、犯行の発覚を防ぐ目的で、Aを砂浜に運んで放置し、その結果、Aが砂を吸引して窒息死した。この場合、甲には、殺人罪が成立する。

No53	行為者の認識	正答率
R4-1	正 解 1、3 (順不同)	83%

1 誤っている

本記述は、甲には、覚醒剤の営利目的輸入罪が成立するとしている点で、誤っている。

最決昭 54.3.27。判例は、主観的には覚醒剤取締法の輸入罪を犯す意思で、客観的には麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪に当たる事実を実現した事案において、「両法は、その取締の目的において同一であり、かつ、取締の方式が極めて近似して、輸入、輸出、製造、譲渡、譲受、所持等同じ態様の行為を犯罪としているうえ、それらが取締の対象とする麻薬と覚せい剤〔注：覚醒剤、以下同じ。〕とは、ともに、その濫用によつてこれに対する精神的ないし身体的依存（いわゆる慢性中毒）の状態を形成し、個人及び社会に対し重大な害悪をもたらすおそれのある薬物であつて、外観上も類似したものが多いことなどにかんがみると、麻薬と覚せい剤との間には、**実質的には同一の法律による規制に服しているとみうるような類似性がある**というべきである。」とし、「**両罪は、その目的物が覚せい剤か麻薬かの差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であり、その法定刑も全く同一であるところ、前記のような麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は実質的に全く重なり合っているものとみるのが相当であるから、麻薬を覚せい剤と誤認した錯誤は、生じた結果である麻薬輸入の罪についての故意を阻却するものではない**」としている。本記述の甲は、麻薬であるヘロインの粉末を覚醒剤と誤信して営利目的で輸入しているところ、ヘロインの営利目的輸入罪と覚醒剤の営利目的輸入罪の法定刑は同一であった。この場合、甲にはヘロインの営利目的輸入罪の故意が認められる。したがって、甲には、ヘロインの営利目的輸入罪が成立する。

2 正しい

最決昭 56.12.21 により、本記述は正しい。

判例は、被告人が、A及びBとの間で、被害者らがD方に押し掛け又は喧嘩となるなどの事態になったときは被害者を殺害するのやむを得ないとの殺害の共謀をし、現実には殺害の実行に着手すべき事態については、Aら現場に赴く者の状況判断に委ねられたという事案において、「**謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする被告人の意思そのものは確定的であつたのであり、被告人は被害者の殺害の結果を認容していたのであるから、被告人の故意の成立に欠けるところはない**」としている。本記述では、甲は、乙に対し、Aとの間でもめごとが起きた場合にはAを殺害してよいが、実際にAを殺害するかは乙の判断に任せる旨伝えて拳銃を渡しているところ、甲は、乙とAの間でもめごとが起きることがあり得ると認識していた。したがって、甲には、殺人罪の故意が認められる。

3 誤っている

本記述は、甲には、Bに対する殺人未遂罪が成立しないとしている点で、誤っている。

最判昭 53.7.28（百選 I 42 事件）。判例は、Aに対する強盗殺人の故意でピョウを発射したもののAを殺害するには至らず、かつそのピョウが通行人Bにも命中したもののBは死亡しなかったという事案において、「**犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる**」としつつ、「被告人の右殺人未遂の所為は同巡査に対する強盗の手段として行われたものであるから、強盗との結合犯として、被告人のAに対する所為についてはもちろんのこと、Bに対する所為についても強盗殺人未遂罪が成立するというべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、構成要件に該当する事実を認識していれば規範の問題に直面するので、犯人が具体的に認識

した客体以外の客体に結果が生じても故意は阻却されず、また、故意の内容を構成要件内で抽象化する以上、故意の個数は問題にならないということを挙げている。本記述の甲は、殺意をもってAに向けて拳銃を発射したところ、その弾丸がAを貫通し、その背後にいて甲がその存在を認識していなかったBにも命中し、その結果、Aが死亡し、Bが重傷を負っている。この場合、甲には、A及びBのいずれに対しても殺人罪の故意が認められる。したがって、甲には、Aに対する殺人罪及びBに対する殺人未遂罪が成立する。

4 正しい

大判大13.4.29により、本記述は正しい。

判例は、人を教唆して他人に暴行を加えさせた以上は、その暴行の結果他人の身体を傷害し、よって死に致らせた場合には、教唆者は傷害致死の罪責を負うべきことは当然であるとして、結果的加重犯の重い結果を教唆者に帰責させることを認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、結果的加重犯の重い結果に過失を不要とする判例（最判昭26.9.20）の立場からは当然のことであるということを挙げている。本記述の甲は、乙にAへの暴行を教唆した時点でAが死亡する可能性を予見していなかったが、乙にAへの暴行によってAが死亡した以上、甲にもAの死亡結果を帰責できる。したがって、甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。

5 正しい

大判大12.4.30（百選I15事件）により、本記述は正しい。

判例は、殺意を持って被害者の首を絞めたところ被害者がぐったりしたため死んだと思い込んだ被告人が、犯行の発覚を防ぐ目的で砂浜に被害者を捨てたが、被害者は実はまだ生きており、首を絞められたことと砂末を吸い込んだことにより死亡したという因果関係の錯誤が問題となった事案において、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関係が認められるとしている。そして、本判決は、因果関係の有無だけを問題として殺人罪の成立を肯定しているのであるが、結論としては、因果関係の錯誤は故意を阻却しないとの立場を黙示的に採ったと解されている。本記述の甲は、殺意をもってAの首を絞めたところ、Aが動かなくなったので、Aが死亡したものと誤信し、犯行の発覚を防ぐ目的で、Aを砂浜に運んで放置し、その結果、Aが砂を吸引して窒息死した。したがって、甲には、殺人罪が成立する。

以上により、誤っている記述は1と3であり、したがって、正解は肢1と肢3（順不同）となる。